

1500489-91.2022.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Roberto Sylla

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... de prova: 'Penal e Processual Tráfico ilícito de entorpecentes Prova Depoimentos de policiais Indícios e circunstâncias que convencem da autoria Condenação mantida (...).Depoimentos de policiais, isentos de suspeita, aliados à confissão informal, são elementos mais que suficientes à condenação pelo narcotráfico' (Apelação Criminal n., de São José, rel. Des. Amaral e Silva , j. Em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

1ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes. 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500489-91.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500489-91.2022.8.26.0583

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR HUGO REIS GONÇALVES

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Roberto Sylla

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra VITOR HUGO REIS GONÇALVES, qualificado à fls. 07, imputando-lhe a prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia: "Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 10 de junho de 2022, por volta das 04h09min, na Rua Antônio Rodrigues, nº 91, Vila Mendes, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, o denunciado guardava, tinha em depósito e trazia consigo drogas, para fins de fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, consistente em: (i) 07 (sete) porções de cocaína, na forma de crack, com peso líquido total de 34,91g (trinta e quatro gramas e noventa e um centigramas - lacre nº 0036594), e (ii) 01 (uma) porção de Cannabis Sativa Lineu, popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 70,59g (setenta gramas e cinquenta e nove centigramas - lacre nº 0036595), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme boletim de ocorrência de fls. 09/11,

auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, fotografias de fls. 14/17, laudo de constatação provisório de fls. 20/22 e exame químico-toxicológico definitivo de fls. 82/84. Segundo se apurou, o denunciado VITOR HUGO adquiriu as drogas acima descritas de terceira pessoa até o momento não identificada, guardou e manteve em depósito em sua residência a porção de maconha e trouxe consigo as porções de crack na data dos fatos, as quais seriam destinadas à comercialização. Policiais militares, em patrulhamento pela Rua Mendes de Moraes – onde comumente ocorre o tráfico de drogas –, avistaram o denunciado, trajando uma blusa preta, o qual foi preso recentemente no mesmo local. Ao notar a viatura, o imputado correu pela linha férrea e subiu no telhado de uma residência situada em frente à Rua Antônio Rodrigues, nº 91, Vila Mendes, nesta urbe. Franqueada a entrada pela moradora da casa, os agentes públicos localizaram o imputado no corredor ao fundo do imóvel e, em revista pessoal, constataram que ele trazia consigo 07 (sete) porções de cocaína, na forma de crack, com peso líquido total de 34,91g. Na ocasião da abordagem, VITOR HUGO admitiu aos policiais que trafica drogas, havia acabado de chegar à linha férrea e ficaria naquele local “até a droga acabar”, revelou, ainda, que em sua casa havia maconha, o que corroborou em seu interrogatório (fl. 07). Na residência do imputado, a genitora dele franqueou a entrada aos policiais militares e entregou-lhes a porção de maconha, com peso líquido de 70,59g, que estava armazenada no guarda-roupas do denunciado, além de dois aparelhos de telefones celulares e o documento dele. Considerando as circunstâncias em que se deram os fatos, somadas à significativa quantidade e variedade de drogas apreendidas, afigura-se quadro seguro a apontar que as drogas seriam destinadas ao tráfico de substâncias entorpecentes, razão pela qual o denunciado foi conduzido à Delegacia de Polícia e preso em flagrante delito”. Acompanha a denúncia o respectivo inquérito policial.

Após regular citação apresentado defesa preliminar (fls. 108/109), sobre a qual o Ministério Público se manifestou (fls. 113), o despacho de fls. 115/119, de 29 de julho de 2022, recebeu a denúncia e determinou a produção de provas.

Em alegações finais, o nobre Dr. Promotor de Justiça (fls. 202/203), pediu a parcial procedência da ação penal, com a condenação do réu por tráfico de drogas nos termos da denúncia. Por sua vez, o ilustre Dr. Defensor Público (fls. 254/268), arguiu preliminarmente, da quebra da cadeia de custódia, já que não foi isolado o local para colheita da prova material do crime, simplesmente foram apreendidas e apresentadas na Delegacia, mas não consta nos autos o isolamento do vestígio que foi encontrado, conforme determina o artigo 158-B, §2º, do Código Penal, não havendo o rastreamento integral da prova desde a abordagem e encontro até a apresentação à Autoridade Policial, ficando impossível o exercício da ampla defesa e do contraditório quanto a droga apresentada, daí decorre a prova ilícita, já que o artigo 158-C, §2º, do Código Penal, indica que a remoção do vestígio antes da liberação e isolamento, é vedado podendo ser considerado, inclusive, fraude processual, uma vez que ficou amplamente demonstrado nos autos que a porção encontrada com o réu é mesmo aquela apresentada na Delegacia de Polícia, assim, essa prova já está inquinada de ilicitude e toda a prova daí decorrente também está contaminada por derivação, devendo ser o réu absolvido nos termos do artigo 386, inciso II ou VII, do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela absolvição do réu por ausência de prova da efetiva participação do réu nos fatos, na forma do artigo 386, inciso V e VII, do Código de Processo Penal, ou, alternativamente, quando a destinação do entorpecente, também não há prova de que o réu traficava droga, já que admitiu que era para seu consumo próprio a maconha, e à mingua de provas em sentido contrário, há que se presumir que toda a droga era para seu uso, devendo ser a acusação desclassificada para aquela prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, nos termos do artigo 383, do Código de Processo Penal. Quanto a eventual condenação, requer a aplicação em seu mínimo legal, em regime diverso do fechado, seja reconhecida a menoridade relativa e a figura do tráfico privilegiado, ante a ausência de condenações anteriores, bem como a substituição da penal por restritiva de direitos e o regime aberto para cumprimento.

É o relatório.

DECIDO.

Rejeito a preliminar arguida pelo nobre Dr. Defensor Público, que alega nulidade da prova porque não foi observada ou obedecida ou mantida a chamada CADEIA DE CUSTODIA, instituída no Código de Processo Penal, pela recente reforma processual da lei n. 6.341/2019, mais conhecido como “pacote anticrime”.

A princípio, a não observância das regras da Cadeia de Custódia não gera nulidade ou ilicitude da prova, porque há outras formas de se reconhecer a sua autenticidade.

No caso dos autos o acusado e sua defesa contestam como a droga foi apreendida e apresentada na Delegacia de Polícia sem sequer ter sido isolado o local, acondicionado em recipiente ou local próprio para o transporte, com a obrigatoriedade de rastreamento da droga e objetos do crime, desde a abordagem até a apresentação na Delegacia, mas, em contrapartida, não negam que a droga foi encontrada no local e na forma mencionada na denúncia e informado pelos policiais militares que realizaram a diligência, contestando apenas a forma como foi apreendida e apresentada na Delegacia.

Para BADARÓ, Gustavo, A Cadeia de Custódia e sua Relevância para a Prova Penal. In: SIDI, Ricardo; LOPES, Anderson Bezerra (Org). Temas Atuais da Investigação Preliminar no Processo Penal. Belo Horizonte: Editora D'Plácido, 2017, p. 533.

Complementa o autor: “(...) as irregularidades da cadeia de custódia não são aptas a causar a ilicitude da prova, devendo o problema ser resolvido, com redobrado cuidado e muito maior esforço argumentativo, no momento da valoração (...) se considerar atendível um meio de prova, decorrente de fonte sobre a qual haja irregularidades na cadeia de custódia, haverá uma inegável necessidade de reforço justificativo demonstrando o porquê ser possível confiar na autenticidade”. (p.535-536).

Ressalte-se, outrossim, que o inquérito é mero procedimento administrativo-informativo, razão pela qual as investigações realizadas pela autoridade policial não se confundem com instrução criminal, motivo pelo qual eventuais irregularidades por integridade de tal fonte, por ventura nele ocorridas, não são capazes de ensejar nulidade do processo, o qual, no caso em análise, transcorreu de forma regular e sem vícios, conforme se constatou de todo o arcabouço probatório amalhada aos autos.

Oportuno, ainda, frisar que “em processo penal, vigoram os princípios de que “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (art. 563 do CPP)” (STJ 5ª Turma, RHC nº 38.424/MG, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 07/03/2005).

Quando ouvido nos autos em sede inquisitiva, confessou o tráfico e admitiu que a droga era para venda a terceiros, e que ficaria no local até vender tudo, porém, em juízo, negou a prática dos fatos da denúncia e a posse e propriedade da droga apreendida, afirmando apenas que foi agredido e acusado injustamente pelos Policiais Militares Matheus e Cavali, o que não se mostra crível, já que, conforme comprova os documentos de fls. 161/164, como ele disse que o PM. Matheus prometeu que lhe prejudicaria, tais documentos mostram que dias antes ele teria sido preso por outros policiais militares, dessa forma, somente tenta se esquivar da responsabilidade criminal, para se manter em liberdade e evitar que seja novamente abordado por Policiais Militares.

Também é comum que acusados de graves crimes como o destes autos imputem a Policiais Militares, agressão, abuso e tortura, todavia, todas, na grande maioria das vezes, não se confirmam e só é alegado por aqueles que possuem várias acusações graves e o verdadeiro intuito, é se livrar da acusação, como quer fazer crer a d. Defesa do réu, imputando ainda, aos exímios Policiais Militares, nas entrelinhas, perseguição ao réu, somente porque ele é pessoas bastante conhecida dos meios policiais.

Ademais, o procedimento disciplinado para cadeia de custódia apenas se faz necessário quando as circunstâncias do caso concreto exigirem a atuação dos peritos no próprio local do crime, demandando o isolamento, a fixação e a coleta do vestígio por pessoa especializada. Não é esta, porém, a hipótese dos autos, e está longe de ser.

Neste sentido é a jurisprudência:

"ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 1501131-89.2019.8.26.0544, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante CARLOS DANIEL TEIXEIRA DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ACORDAM, em 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram do recurso e, no mérito, deram-lhe parcial provimento para: a) reconhecer a atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa; b) aplicar a causa de diminuição dada pelo art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo; c) modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto; d) impor ao apelante apenas de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e o pagamento de 166 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art.33, §4º, da Lei 11.343/2006; e) substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos nos termos acima indicados. Mantido, no mais, a r. sentença em seus termos. V.U. Presente à sessão de julgamento o Dr. José Augusto Sant'Anna.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA. São Paulo, 6 de abril de 2021. MARCOS ALEXANDRE COELHOZILLI RELATOR. Tráfico de drogas. Recurso da Defesa. 1. Materialidade comprovada pela apreensão das drogas, pelo laudo preliminar de constatação e pelo exame químico-toxicológico. Inexistência de quebra da cadeia de custódia. Substâncias apreendidas por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante e encaminhadas ao Instituto de Criminalística através de invólucros lacrados e numerados, acompanhadas da devida requisição. Menção à numeração dos lacres no laudo de constatação. 2. A mera ausência dos números dos lacres no laudo definitivo não enseja a quebra da cadeia de custódia diante da existência de outros elementos que evidenciem a idoneidade do caminho percorrido pela prova até a sua análise pelo magistrado sem qualquer interferência durante a tramitação processual que conduza a sua imprestabilidade. (...) (...)A defesa pugna pela absolvição por falta de provas relativamente à materialidade delitiva. Para tanto, invoca a quebra da cadeia de custódia. Nesse sentido, aponta para a inexistência de identificação, no laudo definitivo, dos números dos lacres das drogas, afirmando, ademais, que não teriam sido observadas as normas técnicas sobre a formalização da apreensão, acondicionamento, guarda e incineração das drogas previstas na Resolução SSP/336 de 11 de dezembro de 2008. (...)O pleito não prospera. As drogas foram coletadas pelos policiais por ocasião da prisão em flagrante do acusado e encaminhadas para a delegacia onde a autoridade policial determinou a sua apreensão e cuja formalização é ilustrada pelo auto de exibição e apreensão juntado aos autos (fls. 06/07). Todas as porções foram devidamente acondicionadas e lacradas com a respectiva numeração: a) 29 porções de maconha lacre 4076; b) 47 porções de cocaína lacre 4061; e c) 44 porções de crack lacre 4100.As substâncias apreendidas foram encaminhadas ao Instituto de Criminalista para realização de exame preliminar de constatação conforme depreende-se do ofício juntado aos autos (fls. 14). Naquele ofício há descrição pormenorizada das substâncias, com a indicação da respectiva quantidade, natureza, forma de acondicionamento, além da numeração correspondente dos lacres. Posteriormente, foi elaborado o laudo provisório de constatação de nº 177.069/2019, o qual foi firmado por perito oficial do Instituto de Criminalística (fls. 42/44). O laudo, note-se, faz menção ao recebimento de 3 itens para exame pericial os quais estavam acondicionados em invólucros plásticos lacrados com a devida numeração correspondente. Também é descrita a metodologia empregada para a detecção do princípio ativo havendo referência às quantidades das substâncias. Em seguida, acostou-se aos autos o laudo de exame químico toxicológico de nº 177.401/2019, o qual é alvo dos questionamentos expressados pela defesa (fls. 62/65). O laudo, contudo, faz menção ao recebimento de 3 itens acondicionados em invólucros lacrados. Não identifica qual a numeração dos respectivos lacres. A questão envolve mera irregularidade. Afinal, o laudo definitivo faz referência expressa de que as substâncias analisadas ligam-se ao laudo de constatação de nº 177.069/2019. Não há, portanto, qualquer quebra na cadeia de custódia. Ademais, o laudo definitivo ratificou o resultado do exame provisório ao apontara presença do princípio ativo nas substâncias examinadas. A defesa invoca, ainda, a inobservância das normas técnicas sobre a formalização da apreensão, acondicionamento, guarda e incineração

das drogas e que estariam previstas na Resolução SSP/336 de 11 de dezembro de 2008. Não há, contudo, apontamento específico sobre qual norma técnica teria sido descumprida. A alegação é, portanto, marcada pela generalidade. De todo modo, não se vislumbra ilicitude capaz de macular a cadeia de custódia. As drogas coletadas por ocasião do flagrante foram apresentadas à autoridade policial que determinou a sua apreensão e acondicionamento em invólucros lacrados. As substâncias foram encaminhadas ao Instituto de Criminalística por meio de requisição na qual constou a numeração dos lacres. 1 As drogas foram recebidas pelo perito responsável que, após a conferência da numeração do lacre, retirou a quantidade necessária para a realização dos exames de constatação e definitivo. O restante dos entorpecentes, bem como o invólucro e lacre, foram devolvidos à 1 Art. 1º. Nas ocorrências policiais em que houver apreensão de drogas, deverá o produto ser acondicionado em embalagens apropriadas transparentes, as quais serão devidamente lacradas, na presença da Autoridade Policial, do escrivão e dos policiais que efetuaram a apreensão e imediatamente encaminhadas à competente unidade da Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC), mediante o preenchimento da requisição de exame constando o número de lacre daquele lote, além dos dados de praxe da requisição. 2. Não houve, portanto, violação da cadeia de custódia. Foram atendidas as formalidades necessárias à preservação dos vestígios desde o encontro das substâncias até a realização dos exames periciais, inexistindo, dessa forma, elementos de adulteração da prova que pudessem comprometer a demonstração da materialidade delitiva. (...) MARCOS ALEXANDRE COELHOZILLI Relator. Trata-se de simples apreensão de substâncias entorpecentes, as quais foram devidamente encaminhadas ao instituto de criminalística para realização do exame toxicológico, sendo de todo prescindível a análise dos referidos objetos, que nada influi no deslinde do caso.

Na hipótese de apreensão de drogas, basta conferir se o material coletado foi entregue ao órgão responsável pela perícia, analisando a numeração dos lacres dos invólucros o que foi devidamente respeitado.

Os Policiais Militares foram uníssomos, e não se mostraram tendentes a imputar crime tão grave à pessoa inocente. Disseram que durante a abordagem encontraram o réu escondido em uma casa, onde os moradores, assustados com a sua presença, sequer acompanharam a diligência. Após isso, foi dada voz de prisão ao réu e encaminhado, com a droga, e apresentado a Autoridade Policial que formalizou o flagrante delito. Passo à análise do mérito.

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta apurada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

A materialidade dos fatos narrados na denúncia e imputados ao réu encontra-se suficientemente demonstrada nos autos pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12/13; pelo laudo de constatação preliminar de fls. 20/22; pelo laudo químico toxicológico de fls. 82/84, atestando – Item A (Acondicionado sob o lacre 0036594 ) Descrição: 7 (sete) invólucro(s) plástico(s) fechado(s) por nó encerrando porção de material sólido petrificado, de cor bege. Massa Bruta e/ou Quantidade: 40,29 grama(s) - quarenta gramas e vinte e nove centigramas. Massa Líquida: 34,91 grama(s) - trinta e quatro gramas e noventa e um centigramas. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada delgada e foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020) e Item B (Acondicionado sob o lacre 0036595 ) Descrição: 1 (um) invólucro(s) plástico(s) do tipo "filme" retorcido encerrando porção de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos. Massa Bruta e/ou Quantidade: 77,35 grama(s) - setenta e sete gramas e trinta e cinco centigramas. Massa Líquida: 70,59 grama(s) - setenta gramas e cinquenta e nove centigramas. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada delgada e foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de

03/08/2020); pelo laudo pericial no aparelho celular de fls. 136/142; além da prova oral carreada para os autos.

Em Juízo, a testemunha Jéssica Santos Cavalcante, sob o crivo do contraditório declarou que era por volta das 3:00 horas com barulhos vindo do fundo, no barracão e sua cachorra rotwailer latia insistentemente e ao verificar o que havia, viu dois policiais armados e com lanternas em cima do barracão. Ficou muito assustada e percebeu ser sério e foi para frente da sua casa, viu um policial no portão que lhe pediu para prender o cachorro e abrir o portão. Quando eles entraram, encontraram um indivíduo escondido na sua residência.

O PM Matheus Martins Rodrigues, sob o crivo do contraditório declarou que sua viatura estava patrulhando próximo a linha férrea, local já comumente conhecido pelo tráfico de drogas, um indivíduo ao notar a aproximação da viatura, empreendeu fuga, subindo no telhado de uma residência abandonada, que faz fundos com a linha férrea, fugindo pelos telhados. Efetuaram o cerco e pela Antonio Rodrigues, um morador disse ter ouvido barulhos no fundo do seu quintal e franqueou a entrada. No local encontraram o acusado, que com ele tinha 7 porções grande de crack, embaladas e prontas para a venda, com aproximadamente 5 gramas cada uma. Indagado o indivíduo, disse que acabara de chegar ao local e iria fazer o tráfico de drogas e como não tinha nenhum documento com ele, deslocaram-se até a residência dele onde fizeram contato com a mãe do averiguado que lhes entregou o documento e dois celulares. Nesse momento, também foi localizada juntamente com o sargento uma porção de maconha no guarda-roupas que ele disse ser para uso dele. Diante disso foram apresentados na Delegacia.

O PM. Luiz Felipe Cavali, também sob o crivo do contraditório declarou que estavam em patrulhamento na linha férrea, local já comumente conhecido pelo tráfico de drogas, nesse sentido, todos já saem correndo com a aproximação da viatura. Ali próximo há um barracão abandonado onde eles sobem no telhado para se esconderem, e nesse dia, correu um indivíduo, correu para esse barracão, pulou o muro de uma residência vizinha e ali se escondeu. Fizeram o cerco pela Antonio Rodrigues, e em contato com a moradora dessa casa disse que teria ouvido barulhos no quintal e franqueou a entrada. No local encontraram o acusado juntamente com o seu parceiro e com ele tinha 7 porções grande de crack, embaladas e prontas para a venda. Indagado, disse que acabara de chegar na linha férrea e iria fazer o tráfico de drogas e como não tinha nenhum documento com ele, deslocaram-se até a residência dele onde fizeram contato com a mãe do averiguado que já tinha indicado que no guarda-roupas dele tinha mais uma porção grande maconha, que ele disse ser para uso dele. fizeram contato com a mãe do averiguado que apresentou os documentos e juntamente com o Sargento, localizou a droga onde ele teria apontado, mais dois celulares que ela disse não ser dele e que seria de procedência duvidosa. Diante disso foram apresentados na Delegacia.

O depoimento dos policiais é suficiente para alicerçar a culpa do acusado, que deve provar sua inocência com os meios que obtiver.

Transcrevo decisões a respeito do crime ora tratado, relativamente à impossibilidade de desclassificação para uso de entorpecente, bem como sobre a credibilidade da palavra dos policiais envolvidos com a descoberta e detenção dos envolvidos:

“PROVA - Depoimento de policial que efetuou a prisão em flagrante - Declarações harmônicas e seguras - Suporte suficiente à condenação - Inteligência dos artigos 6º, III, e 202 do CPP. PROVA - Depoimento de policial - Credibilidade dos testemunhos em geral enquanto não apresentada razão concreta de suspeição. ((RT 668/275 - TJSP - rel. Des. Jarbas Mazzoni))”.

Nesse ponto, nunca é demais lembrar que “como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial” - “Prova criminal - Testemunha - Hipótese de Tóxico. Depoimentos prestados por policiais. Validade. Presunção 'iuris tantum' de agirem escorreitamente no exercício da função. (TJSP, RJTJSP 125/563). No mesmo

sentido: (RT 591/313 e 654/278).

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. ((STF HC 74.608-0 de São Paulo rel. Min. Celso de Mello DJU 11.04.97, pág. 12.189))”

Observe-se que o depoimento dos policiais foi unânime, seguindo no mesmo sentido e meros desencontros sobre circunstâncias acessórias e paralelas ao núcleo central do comportamento criminoso não são suficientes para retirar a credibilidade que merece a prova testemunhal produzida nos autos, conforme pretende a defesa.

Aliás, não há nos autos qualquer elemento indicativo de que os policiais quisessem incriminar gratuitamente a acusada, motivo pelo qual não se pode desmerecer a fala dos policiais pelo só fato de pertencerem aos quadros da Polícia Militar.

Sobre a validade do depoimento de policiais, relembro que o eminente Ministro Moreira Alves, quando atuava no Supremo Tribunal Federal, deixou assentado que “o simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento” (STF RHC Rel. Min. Moreira Alves JSTF-Lex 125/332).

O Tribunal de Justiça de São Paulo também já decidiu o seguinte:

“Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivo expressos no CPP determinando que a Polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam à prisão em flagrante não autoriza absolvição” (TJSP AC Rel. Carlos Bueno RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

Demais disso, tem-se que “em sede de repressão aos tóxicos, contrapondo-se à palavra do agente à do policial-condutor, prevalece o depoimento do miliciano, salvo existência de prova diversa em contrário” (TACRIM-SP AC Rel. Lauro Malheiros JUTACRIM 30/328), valendo acrescentar que “pequenas divergências em depoimentos prestados pelas testemunhas, sem ofensa à essência do que contém, não são motivos para torná-los imprestáveis” (TJRJ EI Rel. Antônio Carlos Amorim RTJE 70/278).

A testemunha Veridiana Gonçalves dos Reis, é genitora do réu e sobre os fatos disse que em sua casa nunca viu nada, pois não aceita esse tipo de comportamento. Sabe que ele usa maconha e via as porçõeszinhas que ele mesmo comprava para seu uso.

Afirma que ela própria apresentou a maconha encontrada em sua residência aos policiais. Em relação ao crack, não tem nada a informar. Não estava presente quando ele foi preso. Afirmo que os policiais invadiram sua casa, chamando seu filho de marginal e reviraram toda a sua casa, não sabia, ficou assustada e não tinha conhecimento que ele praticava o tráfico. Disse que Victor Hugo possuía um celular, Iphone 7, que ele sempre trabalhou, mas atualmente estava fazendo bicos. O celular encontrado era do seu filho, estava quebrado, e no dia que os policiais invadiram sua casa e entregou o celular para o policial.

A testemunha Luciano de Oliveira declarou que conhece o Victor desde que ele tinha catorze anos e trabalhava com o pai dele. nessa época ele trabalhava no supermercado. Tinha uma fabrica de cadeira e chamou Victor para trabalhar em sua empresa, e durante dois anos que ele trabalhou, nunca viu ele envolvido em nada estranho ou com drogas. É um rapaz muito dedicado, nunca faltou ao serviço, sempre muito prestativo.

O réu Victor Hugo Reis Gonçalves, em seu interrogatório declarou que possui 20 anos e nunca foi preso anteriormente. Sobre os fatos disse que não são verdadeiros, a droga não era sua, inclusive, os policiais o prenderam há um tempo atrás juntamente com um amigo seu, e falou que se o pegasse no mesmo local, o PM Matheus disse que iria lhe forjar droga. No dia dos fatos estava indo para a casa de uma amiga quando viu a viatura e sabendo que ele iria lhe abordar, e sabendo que se ele o pegasse,

iria lhe forjar, correu e pulou dentro de uma casa. foi pego dentro dessa casa e colocou a droga, e a todo momento disse que a droga não era sua, quando ele começou a lhe agredir, estava desistindo a tantos ferimentos, e não aguentando mais, disse que a droga era sua. Disse que foi agredido com tapas no rosto e muitos chutes na sua perna, e no seu corpo. Ficou com o rosto vermelho. Disse que iria na casa de uma amiga sua, chamada Queila, que mora próximo onde foi preso. Em uma data anterior já tinha sido parado pelo PM Matheus e teria dito que ele iria lhe forjar, e foi ao lado de sua amiga Queila e também prendeu um amigo seu, Leonardo Rafael. Nesse dia a Queila estava próxima, mas não sabe se ela ouviu. Somente Leonardo Rafael ouviu o que o Policial Matheus falou.

Encerrando-se a instrução processual.

A negativa do réu não pode ser acolhida, posto que além de não ser confirmada pela prova dos autos, está desmentida por ela, que demonstra de forma segura que os fatos se passaram como narrados na denúncia e a autoria deles pelo réu, além disso, o réu Victor Hugo, já foi preso anteriormente pelo mesmo crime e ainda está respondendo a outros 4 (quatro) procedimento pelo mesmo grave crime de tráfico de drogas.

Ademais, sua confissão em sede policial, pode ser levada em consideração para a sua condenação pelo crime praticado nestes autos, em que pese ter vindo a Juízo, na presença de Defensor Público, relatar apenas que a Polícia Militar de São Paulo agiu com violência, agredindo-o covardemente com tapas no seu rosto e chutes por todo seu corpo e nas pernas, tendo seu rosto ficado apenas vermelho.

Ora, em seu interrogatório quando foi preso em flagrante delito, nada relatou, ainda que perguntado em sua defesa se gostaria de acrescentar algo, disse que não tinha mais nada a relatar, e durante a audiência de custódia disse que foi agredido, e com uma resposta vaga ao questionamento da MM. Juíza de plantão quando indagou se foi agredido, disse "sim", tendo indagado como, ele respondeu "bateu", depois disse que foi agredido com socos na costela, puxaram seu nariz, e que sabia identificar os policiais militares e queria que eles fossem responsabilizados.

Antes disso, teria passado por exame de corpo de delito, conforme se verifica do laudo de fls. 51/52 e nenhuma lesão foi constatada no referido exame, caindo por terra sua justificativa, sendo que sua palavra não é crível, impossível de se lhe dar qualquer crédito, entretanto, como dito alhures, seu depoimento em fase inquisitiva servira como prova para sua condenação, já que em total consonância com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

No caso, estando a confissão informal em consonância com os demais elementos de convicção, consoante apontado, também ostenta valor probatório. Nesse sentido:

A respeito da figura da confissão informal, reproduz-se a doutrina de Guilherme de Souza Nucci: 'O detido poderá dar depoimentos aos policiais na sua casa, no lugar onde foi preso ou mesmo no interior da viatura a caminho da delegacia e essas declarações lhe serão perniciosas no futuro. Não é raro que policiais sejam arrolados como testemunhas de acusação, não do fato delituoso, mas para que contem, em juízo, o que ouviram do réu quando este foi preso. Por certo que tal admissão de culpa, feita fora da delegacia, não é uma confissão, no sentido jurídico do termo, mas não deixa de ser um importante elemento de prova, constituído, afinal, pelos testemunhos daqueles que a ouviram' (O Valor da Confissão como Meio de Prova no Processo Penal 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 230). A jurisprudência deste Sodalício já consagrou a possibilidade da utilização da confissão informal como relevante elemento de prova: 'Penal e Processual Tráfico ilícito de entorpecentes Prova Depoimentos de policiais Indícios e circunstâncias que convencem da autoria Condenação mantida (...).Depoimentos de policiais, isentos de suspeita, aliados à confissão informal, são elementos mais que suficientes à condenação pelo narcotráfico' (Apelação Criminal n., de São José, rel. Des. Amaral e Silva , j. Em 8/1/2009)." (em TJSP, Apelação n. 0028006-47.2013.8.26.0071, rel. Des. Paulo Rossi, j. 03/02/2016).

"É sabido que a confissão deve ser avaliada pela força de convencimento que nela se contém, e não pelo local onde ela é prestada. Vale dizer, a confissão extrajudicial corroborada pela palavra de testemunhas, bem como por outros elementos objetivos de prova, não pode ser invalidada pela retratação, em pretório, sem qualquer



explicação plausível para a confissão policial e com nova versão totalmente inverossímil.”(TJSP, Apelação n. 9230875-35.2008.8.26.0000, rel. Silmar Fernandes, j. 10/05/2012).

“ENTORPECENTE - Tráfico - Configuração - Materialidade e autoria demonstradas - Prova - Confissão policial de corréu - Retratação judicial isolada - Palavra de policiais - Validade - Quantidade e modo de acondicionamento que revelam o fim de comércio - Flagrante preparado - Inocorrência - Pena - Pretendida substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Crime hediondo - Regime integralmente fechado - Manutenção - Recursos não providos.” (Apelação Criminal n. 281.880-3 - Guaratinguetá - 4ª Câmara Criminal - Relator: Passos de Freitas - 08.02.00 - V.U.).

Com efeito, a quantidade de droga apreendida e pertencente ao réu (07 porções de crack pesando 34,91 gramas e 1 porção de maconha pesando 70,59 gramas), além das circunstâncias que se desenvolveram os fatos, são suficientes para comprovar a materialidade delitiva in casu.

Ademais, o desencontro das versões apresentadas pelo réu, acaba se confundindo entre eles, justamente porque não encontram justificativas para a droga, além disso, tenta a todo momento desviar a atenção e o foco para da sua responsabilidade criminal, imputando aos Policiais agressão e que teriam intrujado drogas para incrimina-lo injustamente, fato que não se comprovou, portanto, sua versão é fantasiosa e desconexa com o conjunto probatório coligido aos autos.

Os demais elementos de prova dos autos demonstram a ocorrência do delito de tráfico de drogas diante da conduta do réu, não só pela apreensão das drogas nos dias dos fatos, mas pela ocorrência dos fatos como informado através da Polícia Militar; não só da droga, o que por si só, já denotam o crime de tráfico, aliada a forma como a droga foi encontrada, sete porções grandes de crack que pesaram cerca de 35 gramas, fracionadas para a venda, além da maconha encontrada em sua residência. Outrossim, a droga apreendida, conforme se vê nas fotografias de fls. 14/17, corroborado com os depoimentos dos policiais, era suficiente para demonstração da traficância.

Por outro lado, desnecessário a apreensão de apetrechos para a configuração do crime.

Tais testemunhos autorizam o reconhecimento da autoria e materialidade delitivas contidos nos autos, anotando-se que a palavra da testemunha se reveste de coerência, robustez e segurança e não demonstra qualquer tendência para o exagero ou falsidade, devendo ser aceita como elemento hábil à condenação, suportando o acusado, então, o ônus de contrastá-la, o que não fez.

Pelos detalhes acima extraídos da prova dos autos, não se pode acolher a negativa do réu em Juízo e nem o pedido de desclassificação para o delito posse para consumo pessoal, já que é evidente a condição de traficante do réu.

Quanto à destinação dos entorpecentes apreendidos nos autos, imperioso salientar que o elemento subjetivo do tipo penal do artigo 33 da Lei de Tóxicos não é perceptível logo de início, mas através das circunstâncias externas do caso concreto, as quais acabam por traduzir a intenção dos agentes.

Na hipótese dos autos, a droga apreendida, aliada ao modo como foram encontradas, denota sua destinação ao comércio ilegal.

É o quanto basta para embasar a condenação.

Nesse sentido: “CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - Tráfico - Circunstâncias que induzem a caracterização do delito. A existência de denúncias anônimas, a diversidade e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, parte embalada e pronta para a venda clandestina, são circunstâncias que induze a caracterização do tráfico.” (Apelação Criminal n.º 223.036-3 - Sorocaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 01.07.97 - V.U.);

“TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Circunstâncias que evidenciam a condição de traficante - Recurso não provido. Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu, no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a sua prisão.” (Apelação Criminal n.º 152.279-3 - Marília - 3ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 19.06.95 - V.U.).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Configuração - Materialidade e autoria demonstradas - Prova - Confissão policial de co-réu - Retratação judicial isolada - Palavra de policiais - Validade - Quantidade e modo de acondicionamento que revelam o fim de comércio - Flagrante preparado - Inocorrência - Pena - Pretendida substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Crime hediondo Regime integralmente fechado - Manutenção - Recursos não providos." (Apelação Criminal n. 281.880-3 - Guaratinguetá - 4ª Câmara Criminal - Relator: Passos de Freitas - 08.02.00 - V.U.).

Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga à terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercancia se destina o tóxico encontrado.

Nesse sentido: "Não é indispensável a aprova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido" (TJSP RT 729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3,3.8.94, p.8745); "Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a prisão" (Ap. Crim. 152.279.3, 3ª Câmara, j. 19.06.95 Rel. Des. Bittencourt Rodrigues).

No caso dos autos a polícia tem várias denúncias com informações que indivíduos vinham realizando o tráfico de drogas no local e da forma como constatarem os policiais, pois é local é bastante conhecido de toda a população desta cidade. Nem mesmo as testemunhas que tentaram dar um ar de veracidade a negativa do réu, posto que as versões delas não se harmonizam com as declarações as demais provas dos autos. Ou seja, são contraditórios os relatos, que não merecem nenhuma credibilidade.

Diante de tudo que foi amealhada aos autos, impossível acolher o pedido da Defesa do réu para desclassificação do delito de tráfico para o de porte de droga para consumo pessoal, já que, ao contrário do que alega a defesa, as provas produzidas são suficientes para crer que o réu realizava efetivamente o comércio de drogas na residência, sendo certo que o traficante, muitas vezes, também é usuário de droga, sem perder a qualidade primária, procedendo a ação penal como pedido na denúncia.

Neste sentido:

"Tráfico de entorpecentes. Autoria e materialidade comprovadas. Quantidade de droga e a forma de acondicionamento demonstram a traficância. Impossibilidade de desclassificação para o uso. Depoimentos de policiais, contra os quais nada de concreto se alegou. Condenação bem proferida. Possibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/06. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena. (Ap. Criminal nº 990.10.183740-4 - Registro - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator Desembargador Francisco Bruno).

A propósito:

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229-3, Rel. Onei Raphael - RJTJSP 10/498).

"Tóxico Tráfico Desclassificação - Inadmissibilidade - Ausência de prova de que a droga apreendida destinava-se ao uso exclusivo do réu - Ônus da prova a cargo da defesa - Condenação mantida para o crime de tráfico que restou indubitavelmente comprovado nos autos." (Apelação Criminal n.º 270.095-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Debatin Cardoso - 24.06.99 - V.U.).

Destarte, as provas produzidas permitem a certeza de que o réu se conduziu com vontade livre e consciente de trazer consigo a droga e manter em depósito, com isto, auferir lucro fácil, não podendo ser acatadas as teses da Defesa de insuficiência probatória, negativa de autoria e desclassificatória para o artigo 28, da Lei em comento.

Por fim, conclui-se, destarte, que os réus realizaram conduta antijurídica,

subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se-lhe a condenação e a pena, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes. Procede pois, a ação penal e de rigor a condenação do réu por tráfico de drogas. Inicialmente, verifico que o processo mencionado pelo i. Representando do Ministério Público em suas alegações finais não podem servir para exasperação da pena base, e nem para efeito de reincidência, já que, embora haja vários processos em andamento, não se tem ainda, a ocorrência do trânsito em julgado definitiva da decisão, portanto, não acolho o pedido ministerial para exasperação da pena, justificando que o réu se dedica a atividade criminosa.

Pois, que no julgamento do Recurso Extraordinário n. 591.054 (Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 26.2.2015), submetido à sistemática da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou a tese de que “a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena”.

Nessa linha de entendimento, no julgamento do Habeas Corpus n. 151.431 (Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 8.5.2018, Segunda Turma), o Ministro Gilmar Mendes sustentou que inquéritos e ações penais em curso tampouco podem servir de fundamento para afastar a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo acompanhado pelo Ministro Ricardo Lewandowski. Os Ministros Dias Toffoli e Edson Fachin divergiram do relator, mas, pelo empate, a ordem foi concedida, nos termos da seguinte ementa: “Habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. Condenação. 3. Causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006. 4. Não aplicação da minorante em razão de sentença sem trânsito em julgado. 5. Paciente primário. 6. Ausência de provas de que integra organização criminosa ou se dedique à prática de crimes. 7. Decisão contrária à jurisprudência desta Corte. Constrangimento ilegal configurado. 7.1. O Pleno do STF, ao julgar o RE 591.054, com repercussão geral, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, firmou orientação no sentido de que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena. 7.2. Para efeito de aumento da pena, somente podem ser valoradas como maus antecedentes decisões condenatórias irrecorríveis, sendo impossível considerar para tanto investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso LIV (presunção de não culpabilidade), do texto constitucional. 8. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Superação. 9. Ordem concedida parcialmente para que o Juízo proceda à nova dosimetria” (HC n. 151.431, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.5.2018).

Em 27.11.2018, essa orientação foi firmada pela Segunda Turma, em julgamento unânime: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. PROCEDIMENTOS E/OU PROCESSOS CRIMINAIS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA PARA APLICAR A MINORANTE FUNDAMENTADAMENTE E RECALCULAR A DOSIMETRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em “investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso LIV (presunção de não culpabilidade), do texto constitucional” (HC 151.431/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. II – A escolha do patamar de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não prescinde de adequada fundamentação. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 144.309-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.11.2018).

Considerado entendimento assentado pela Segunda Turma do STF no julgamento do Agravo Regimental do Habeas Corpus n. 144.309, não podem inquéritos ou ações penais em curso fundamentar o afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Por esses argumentos é que não acolho o pedido do Ministério Público em não conceder a redução de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no

caso dos autos, posto que o réu embora registre outros antecedentes, não tem condenação transitada em julgado.

No tocante à circunstância específica prevista no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, no aumento da pena base em decorrência da quantidade, da diversidade das drogas e sua natureza das mesmas; e a aplicação desses mesmos motivos, quantidade, diversidade e natureza das drogas para negar a redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem-se que não é possível por violar o princípio do bis in idem bis.

"Habeas corpus. 2. Dosimetria. 3. Tráfico de drogas. 4. A quantidade de drogas, por si só, não pode proporcionar a presunção de que o paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. Ausência de fundamentação idônea apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 5. Quantidade da droga valorada na primeira e na terceira fase da dosimetria. Bis in idem. Desproporcionalidade no cálculo. 6. Ordem concedida para que seja refeita a dosimetria, nos termos do acórdão. (STF; HC 145362, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 19-03-2020 PUBLIC 20-03-2020).

Neste ponto, é forçoso reconhecer que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos HCs n.º 112776 e n.º 109193, em 19/12/2013, decidiu que não é possível a utilização cumulativa da quantidade e da natureza da droga na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena, sob pena de incorrer em bis in idem:

"[...] HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE E NA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. BIS IN IDEM. OBRIGATORIEDADE DO REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA.

INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º, DO ART. 2º, DA LEI 8.072/1990. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/06, "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". Configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução). Essa opção permitirá ao juiz aplicar mais adequadamente o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) em cada caso concreto. 2. O magistrado sentenciante considerou a natureza e a quantidade de droga simultaneamente na primeira e na terceira fase de individualização da reprimenda, em flagrante bis in idem. [...]" (HC 112776, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).

Também decidiu: "[...] HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA SOMENTE NA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. LEGITIMIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PACIENTE CONDENADO À PENA DE RECLUSÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, I, DO CP. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/06